

Processo: 1.0000.24.303113-5/001
Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques
Relator do Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques
Data do 22/10/2024
Data da 23/10/2024

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - NECESSIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA - QUANTIDADE INFERIOR A 40G - PRESUNÇÃO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 635.659 - TEMA 506 - ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA - REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 635.659 - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

- Certa a posse, mas incerta a finalidade, não há como manter a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

- É imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prova da destinação comercial da substância, sendo necessária a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando não comprovado o dolo específico de mercancia.

- Diante do julgamento do STF no RE nº 635.659, que, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, quando o usuário portar menos de 40g de maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do apelante, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.24.303113-5/001 - COMARCA DE CARATINGA - 1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG - 2º APELANTE: KAIQUE AUGUSTO DA SILVA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG, KAIQUE AUGUSTO DA SILVA

A C Ó R D ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES
RELATOR

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES (RELATOR)

V O T O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e por KAIQUE AUGUSTO DA SILVA contra a r. sentença (doc. 68), que julgando procedente em parte a ação penal, condenou o denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/ §4º, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Além disso, a r. decisão fixou em desfavor do réu indenização no valor de 01 (um) salário mínimo vigente para a reparação dos danos causados pela infração.

Sobre os fatos, relata a denúncia (doc. 01):

"Consta-se do incluso inquérito policial que, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 15h16min, na Travessa Jorge Coura Filho, nº 69, Centro, em Caratinga - MG, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito,

consistentes em 05 buchas de maconha com massa total de 6,59g (seis gramas e cinquenta e nove centigramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, no fatídico dia, policiais militares, após receberem denúncias anônimas relativas ao tráfico de drogas, iniciaram patrulhamento a fim de localizar e abordar o denunciado, oportunidade em que o avistaram pilotando a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa GRS-2D71, em via pública.

Na ocasião, a equipe policial deu ordem de parada ao denunciado que, ao perceber que seria realizada busca pessoal, empreendeu fuga a pé, contudo, foi alcançado pelos militares.

Na sequência, ao procederem com a busca pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, com massa total de 6,59g (seis gramas e cinquenta e nove centigramas), alocadas dentro de sua cueca."

A denúncia foi recebida em 30/05/22 (doc. 22) e o processo seguiu os trâmites legais, culminando com a sentença condenatória mencionada (doc. 68), publicada no dia 12/08/23 (PJE), da qual KAIQUE foi intimado pessoalmente, ocasião em que manifestou interesse em recorrer (doc. 82).

Nas razões recursais (doc. 96), a Defesa pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente extinção da punibilidade do réu em razão do reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para redução da pena aquém do mínimo legal. Além disso, pugnou pelo decote da indenização fixada pelo dano moral coletivo. Requereu, por fim, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais (doc. 100), manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para fazer incidir a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sem reflexos na pena intermediária, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

Igualmente insatisfeito, o Parquet interpôs recurso de apelação (doc. 78). Em suas razões recursais, pleiteou, em tese única, o perdimento do veículo apreendido, ante sua comprovada utilização no tráfico de drogas.

Contrarrazões defensivas apresentadas no doc. 95, manifestando-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo ministerial interposto.

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou (doc. 102), opinando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo defensivo e integral provimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Conheço dos recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares suscitadas ou nulidades que devam ser declaradas de ofício, passamos ao exame do mérito.

Pleiteia a Defesa, em tese principal, a desclassificação da conduta para o tipo penal inserto no art. 28 da Lei Federal nº 11.343/06.

Razão lhe assiste.

A materialidade fora demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (doc. 03 - fls. 12/16); Auto de Apreensão (doc. 03 - fl. 17); Exame Preliminar (doc. 03 - fl. 18) e; ainda, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (doc. 52).

Contudo, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório não permite, com o juízo de certeza necessário, indicar que o réu estava realmente traficando drogas na data dos fatos como narra a

denúncia.

Ao ser interrogado na fase inquisitiva (doc. 03 - fls. 05/06), o acusado admitiu a propriedade das 05 (cinco) buchas de maconha apreendidas, alegando que se destinavam somente para seu consumo pessoal. In verbis:

"(...) o declarante esclarece que comprou a droga ora apreendida para consumo próprio; QUE comprou 5 buchas por 25 reais; QUE não tinha intenção alguma de comercializar as buchas de maconha; (...)"

Em juízo (PJe Mídias), o acusado manteve a firme versão de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio. In verbis:

"que fuma maconha; que estava em casa com sua namorada até que sua mãe falou que sairia para fazer unha; que em seguida sua namorada foi embora, quando pegou a moto de sua mãe e foi comprar 5 buchas de maconha, totalizando 25 reais; que seria usada para consumo próprio; que ao avistar os policiais, empreendeu fuga para não ser preso em posse da droga; que não tinha interesse de comercializar a droga apreendida; que não tem problema com ninguém; que a moto pertencia a sua mãe; que não estava em posse de dinheiro; que no momento da abordagem estava indo para casa para saber se sua mãe estava lá e depois iria para a casa de sua namorada para fazer uso da droga adquirida" (grifamos).

Por sua vez, o policial militar CRISTIANO SOARES CARDOSO confirmou em juízo o histórico da ocorrência. Disse que estava de apoio ao fato, mas não se lembra dos demais fatos da ocorrência (PJe Mídias).

Em juízo, a testemunha IGOR FREDERICO JACINTO DE SIQUEIRA disse que não se recordava dos fatos (PJe Mídias).

Em juízo, a testemunha HENRIQUE DE SOUZA BRAGA confirmou na íntegra o teor do boletim de ocorrência. Afirmou que, no dia dos fatos, estava sendo realizada uma operação que visava o combate dos crimes contra o patrimônio praticados com o uso de motocicletas; que ao avistar os policiais, o autor teria acelerado, momento em que teriam iniciado seu acompanhamento; que o autor parou em dado momento para ser abordado, mas empreendeu fuga em seguida; que posteriormente foi abordado em posse das drogas; que havia denúncia em face do acusado; que a droga estava escondida em suas roupas íntimas; que haviam outras denúncias em canais diversos de acionamento da Polícia Militar; que não houve contato do réu com terceiros no momento da abordagem; que trabalha há 13 anos em Caratinga e que não teve acesso ao inteiro teor das demais denúncias realizadas através do disque denúncia (PJe Mídias).

Por seu turno, o policial militar FABIANO SANGI DE LIMA afirmou, em juízo, que o réu era alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas e que a polícia já estava em patrulhamento; que no dia dos fatos o réu foi visualizado em uma motocicleta; que após ser realizada a abordagem, foi encontrado em sua posse substâncias entorpecentes; que a abordagem se deu em virtude de denúncias já recebidas, que indicavam que o denunciado traficava na região; que a droga foi localizada em suas vestes; que houve outra abordagem, realizada aproximadamente em dezembro do ano passado; que é de praxe antes de uma operação, os policiais consultarem denúncias pretéritas feitas em desfavor dos denunciados; que não viu o autor em contato com terceiros durante a abordagem (...); apenas disse que ele estava transportando as drogas encontradas (PJe Mídias).

Em juízo, a testemunha RIVALDA CRISTINA DOS REIS esclareceu que o réu mora com sua mãe; que sua família possui condição financeira estável; que o réu faz bicos de servente de pedreiro e na oficina mecânica; que nunca viu o denunciado usar drogas; que já ouviu comentários de que o réu é usuário de drogas; que o autor é pessoa educada e tranquila (PJe Mídias).

Já a informante ESTER AUGUSTA DA SILVA, genitora do acusado, afirmou, em juízo, que o réu mora em sua casa; que é pessoa tranquila; que o acusado faz bicos como servente de pedreiro; que já ouviu dizer que o acusado é usuário de maconha; que o acusado nunca apresentou sinais de agressividade; que a motocicleta foi adquirida para fins de entregas de comidas, pois já teve lanchonete; que trabalha com bicos, sendo um deles como manicure; que a motocicleta estava registrada em seu nome (PJe Mídias).

Inferre-se, portanto, que a prova oral produzida em juízo é bastante frágil e insipiente para comprovar que o réu estivesse praticando o crime de tráfico de drogas na data dos fatos, conforme aponta a acusação.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei Antidrogas, "para determinar se a droga destinava-se à consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analisando as premissas determinadas pelo legislador e o contexto fático-probatório, não vislumbro evidência nos autos de que a droga apreendida se destinava a mercancia ilícita.

A quantidade de maconha apreendida é ínfima (6,59g - seis gramas e cinquenta e nove centigramas - Exame Preliminar no doc. 03 - fl. 18), plenamente compatível para o uso, sendo crível a alegação do réu de que as cinco buchas adquiridas se destinavam para seu consumo próprio.

Além do mais, como visto, os policiais militares não visualizaram o apelante em atitude que indicasse que ele estaria praticando a mercancia ilícita em via pública, tanto é que a abordagem se desenrolou por conta de denúncia anônima e os agentes públicos sequer realizaram prévio monitoramento.

Vale frisar, neste ponto, que os entorpecentes estavam escondidos dentro da cueca do acusado, não tendo ele praticado qualquer conduta relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Além disso, não há sequer a apreensão de alguma quantia em dinheiro que pudesse indicar o lucro proveniente da mercancia ilícita de entorpecentes.

Aliás, a tese acusatória é tão frágil, que das três denúncias anônimas juntadas nos autos (doc. 03 - fls. 19, 20 e 21) que supostamente justificaram a abordagem do réu em via pública, uma delas nem sequer se refere ao ora apelante, mas sim a um indivíduo conhecido por "ALTAIR".

Partindo dessa premissa, apesar da apreensão das cinco buchas de maconha na posse do réu, temos que, após aprofundada análise dos autos, as provas acostadas não foram claras no sentido de comprovar que o acusado estaria, no contexto da apreensão, realmente imbuído da intenção de traficar entorpecentes.

Assim, reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas se mostra temerário.

Com isso, não se está aqui dizendo que o réu não tenha envolvimento algum com o tráfico, apenas que não há prova suficientemente sólida para se concluir que, neste caso específico, ele trazia drogas consigo para fins mercantis, havendo somente, acerca deste ponto, meras e frágeis suposições encabeçadas pelo Parquet.

Dessa forma, não se incumbindo, a contento, o órgão acusatório de seu onus probandi, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe.

Por tais razões, procedo à desclassificação da imputação constante da denúncia para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Enfatiza-se que, no recente julgamento, em 26 de junho de 2024, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral, ata de julgamento publicada no DJe de 28/06/2024), decidiu o seguinte:

Por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para:

i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e

ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Não votou, no mérito, o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior.

Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese:

"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.

Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário".

Ficaram vencidos: no item 1 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux; no item 2 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques; no item 3 da tese, o Ministro Luiz Fux; no item 4 da tese, os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux; e, nos itens 5 e 7 da tese, o Ministro Luiz Fux. Votou na fixação da tese o Ministro Flávio Dino.

Por fim, o Tribunal deliberou, ainda, nos termos do voto do Relator:

1) Determinar ao CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tribunais e CNMP, a adoção de medidas para permitir:

(i) o cumprimento da presente decisão pelos juízes, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal;

(ii) a criação de protocolo próprio para realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas CAPS AD;

2) Fazer um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas;

3) Conclamar os Poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas (i) no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e (ii) na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; (iii) na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei;

4) Para viabilizar a concretização dessa política pública especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários caberá aos Poderes Executivo e Legislativo assegurar dotações orçamentárias

suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), instituído pela Lei 7.560/86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.

Por fim, a Corte determinou que o CNJ, com a participação das Defensorias Públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro André Mendonça, que já havia proferido voto em assentada anterior. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024.

Como visto, restou comprovado que com o apelante foi encontrado apenas maconha em porção inferior a 40g (quarenta gramas). Dessarte, entendo que a Decisão da Suprema Corte, uma vez publicada, deve ser aplicada ao caso em análise, posto que declara a inconstitucionalidade, ainda que sob moldura específica, do dispositivo legal que até então tipificava como crime a posse de maconha destinada a uso próprio.

Assim, tem-se que é atípica a conduta, impondo-se solução absolutória com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Outrossim, cabe reforçar que a conduta atribuída ao apelante, embora não configure mais ilícito penal, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei nº 11.343/06) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei nº 11.343/06), nos termos do que decidiu o STF no julgamento do Tema 506. Desse modo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, para aplicação das medidas administrativas que julgar cabíveis.

No mais, rejeito o pedido defensivo requerendo o reconhecimento da prescrição, em respeito à súmula nº 146 do STF e ao art. 110, §1º, do Código Penal, pois ainda não houve o trânsito em julgado para a acusação, que poderá obter um pronunciamento jurisdicional mais favorável aos seus interesses com eventual interposição de outros recursos, influyendo diretamente no lapso temporal exigido para fins de verificação da perda do jus puniendi estatal.

Registramos, por fim, que diante da absolvição do réu fica prejudicado o recurso ministerial requerendo o perdimento do bem.

Destarte, diante do exposto, **NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA** para desclassificar o crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e, por conseguinte, absolver o réu, nos termos do Tema 506 do STF, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal, competente para exame da ilicitude extrapenal da conduta referente ao porte de maconha para uso pessoal, e eventual aplicação das sanções do art. 28, incisos I e III, da Lei nº 11.343/06, nos termos da r. decisão do Supremo Tribunal Federal.

Custas pelo Estado.

É como voto.

DES. BRUNO TERRA DIAS (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. PAULA CUNHA E SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL"



Tribunal de Justiça de Minas Gerais